

1500693-44.2021.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... e pena menor do usuário de drogas frente ao tráfico. Logo, o crime que é apenado como forma precípua de evitar um outro mais grave, deve receber sempre pena inferior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR a pessoa de MARCOS APARECIDO JOSÉ DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 50, do Decreto-Lei nº 3.688/41, às penas de 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo nº 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

1500693-44.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500693-44.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS APARECIDO JOSÉ DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

MARCOS APARECIDO JOSÉ DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado(a) como incurso nas sanções do artigo 50 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, porque da data e horários descritos na exordial, nesta cidade e Comarca, explorou jogo de azar em local acessível ao público.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo auto de apreensão de fls. 08/09 e pelo laudo pericial de fls. 69/77, que demonstra que as máquinas apreendidas estavam operantes.

A propósito, os elementos colhidos pelo perito indicam que as máquinas de jogos eletrônicos foram localizadas no interior do estabelecimento comercial indicado na denuncia. Ressaltou o perito que foram realizados testes nas máquinas ligadas, constatando-se que se tratavam de equipamentos sorteadores aleatórios de resultados e, por conseguinte, o ganho ou perda independem da habilidade física ou intelectual do apostador, tratando-se de equipamentos utilizados para a prática de jogo de azar. A prova pericial realizada indica que o apostador não interfere no sorteio

realizado pela máquina, de modo que o ganho e a perda independem da habilidade física ou intelectual do apostador.

As máquinas apreendidas são do tipo caça-níquel e executam jogos, cujos resultados independem do jogador e dependem exclusivamente da sorte.

As fotografias juntadas a fls. 71 e 72 mostram, respectivamente, a fachada no estabelecimento comercial onde foi realizada a diligência e as cinco máquinas apreendidas no local.

A operação das máquinas caça-níqueis é considerada como jogo de azar justamente porque, qualquer que seja o resultado, favorável ou não, não depende da habilidade do apostador, mas de impulsos registrados nos equipamentos.

"A exploração de máquinas eletrônicas de concursos prognósticos, como as caça-níqueis, as de videopôquer e similares, efetivamente, configura a prática de jogo de azar, considerada ilegal, podendo ser enquadrada na contravenção penal do artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 ou do artigo 45 do Decreto-Lei nº 6.259/44, ou, ainda, no crime contra a economia popular do artigo 2º, inciso IX da Lei nº 1.521/51. Precedentes do STJ" (HC 15.923/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 13.12.04).

Destarte, tipifica a contravenção prevista no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 a exploração de máquinas caça-níqueis.

Não há que se falar em nulidade ou insuficiência da perícia realizada para comprovação da materialidade delitiva, pois as máquinas foram vistoriadas na ocasião dos fatos. É óbvio que, neste tipo de máquina, existe um percentual de chance de ganhar ou perder ou de ser retido o dinheiro, o que não desconstitui a conclusão supra.

Também não resta qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, pois o réu apresentou-se como o responsável pelo estabelecimento comercial onde foram apreendidas as máquinas.

O réu informou que é proprietário do bar, mas arrendou o bar ao arrendatário e foi este último quem instalou as máquinas no local. Disse que morava na casa do fundo e que passava todo dia no bar para sair/entrar da/casa. Afirmou que não ficou em silêncio na delegacia e que lá disse o mesmo que aqui mencionou.

O policial Anderson confirmou a ocorrência e que a polícia militar foi quem realizou a primeira abordagem. Não se recorda a relação de Marco com o local dos fatos. O policial Nilton reiterou o que disse o policial Anderson, informando que os policiais militares apontaram que Marco seria o responsável pelo local, mas não sabe precisar o que efetivamente ele era no local (atendente, gerente ou proprietário).

Como se verifica, a despeito da incerteza demonstrada pelos policiais civis, o réu confirmou ser o proprietário do bar e que o locava a um terceiro que teria sido quem colocou as máquinas ali. No entanto, na condição de responsável maior do local, passando ali todos os dias, tinha o dever de evitar o resultado. Além disso, não há prova de que ele tenha, efetivamente, arrendado o local a um terceiro, mesmo porque não há contrato e nem houve a identificação deste terceiro. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação, considerando os elementos norteadores do art. 59, "caput", do Código Penal, entendo que não há razão para elevação da pena, posto que a a gravidade do fato foi típica à própria natureza do delito. Não há que se falar em agravamento da pena pela habitualidade, na medida em que o termo "exploração" já considera tal elemento. Assim, certo também que se trata de réu primário, fixo a pena base no mínimo legal: 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase não verifico a presença de qualquer atenuante (lembrando que nesta fase não se pode reduzir a pena aquém do mínimo legal) ou agravante, motivo pelo qual mantenho a pena no mínimo legal: 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase não se identifica causas de aumento ou diminuição, sejam gerais,

sejam especiais. Assim, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Quanto à pena privativa de liberdade, deverá ser cumprida em regime aberto.

Presentes os requisitos do art. 44, I, II e III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pela prestação pecuniária no valor de três salários mínimos, na medida em que não se pode admitir que explorador do jogo receba reprimenda inferior à do participante do jogo, cuja pena é de multa mínima de R\$ 2.000,00. Tal diferenciação segue a mesma lógica que indica pena menor ao receptor frente ao roubador e pena menor do usuário de drogas frente ao tráfico. Logo, o crime que é apenado como forma precípua de evitar um outro mais grave, deve receber sempre pena inferior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR a pessoa de MARCOS APARECIDO JOSÉ DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 50, do Decreto-Lei nº 3.688/41, às penas de 03 (três) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso unitário mínimo, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária equivalente a 03 (três) salários mínimos vigentes quando da data do efetivo pagamento (STJ. ROHC n.º 46.882-ES).

O valor acima deverá ser depositado em conta judicial para posterior reversão à entidades beneficentes cadastradas neste Juizado. As guias deverão ser emitidas conforme orientação constante no link

http://www.tjsp.jus.br/PublicacaoADM/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=78784, item 1.2 (pena de prestação pecuniária).

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, posto que ao caso descabe falar em prisão preventiva, na medida em que regime fechado não é previsto sequer após o trânsito em julgado. Logo, patente é o risco de violação do princípio da homogeneidade entre a prisão cautelas e eventual prisão pena, no caso substituída. Determino o perdimento das máquinas caça niqueis, apreendidas nos autos por se tratar de objeto do ilícito.

Passada a presente em julgado, expeça-se o necessário, inclusive a certidão de honorários em favor de eventual advogado nomeado.

P. I. C.

Mongaguá, 04 de outubro de 2022.